

0000518-73.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

0000518-73.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000518-73.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

William Melquides de Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. WILLIAM MELQUIDES DE CARVALHO qualificado a fls. 16, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de

abril de 2022, por volta das 11h20min, na Avenida 7-A nº 644, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria trazido consigo e teria em depósito, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, uma porção de crack em formato de pedra, pesando 2 g, bem como vinte e quatro microtubos plásticos contendo cocaína, com peso de 19 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “policiais militares receberam informação dando conta de que o denunciado estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência, com o que se deslocaram ao local, oportunidade em que o surpreenderam defronte ao imóvel em atitudes suspeitas. Desta feita, fora ele abordado e com ele apreendidas uma porção de 'crack' de aproximadamente dois gramas, R\$ 420,00 em notas trocadas e uma gilete, comumente utilizada por traficantes para fracionar drogas. Em buscas na residência do averiguado, após autorizados, os policiais apreenderam, em um bote de sorvete sobre um armário, 24 pinos de 'cocaína'.”.

A denúncia de fls. 83/84 foi recebida em 13 de junho de 2022 (fls. 86/87), sendo o Réu citado em fls. 112 e apresentado defesa preliminar em fls. 97/98, rejeitada em fls. 104/107. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 176).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 171/175).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação, alegando não existir prova indicassem ser o Réu narcotraficante, pleiteando a descCLASSIFICAÇÃO para o tipo penal do artigo 28 da lei de regência e, na sequência, absolvendo-o pela insignificância da conduta e, subsidiariamente, requereu aplicação do tráfico privilegiado, impondo regime aberto para cumprimento da pena e substituindo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls. 171/175).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/04, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação preliminar de fls. 12/13, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 166/168, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra o Réu que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ao passo que em Juízo sustentou que a droga era sua, mas não era destinada ao tráfico e sim para o próprio consumo, dizendo que estava bebendo e consumindo entorpecente e para evitar ir a todo momento na biqueira adquiriu aquela quantidade, que seria utilizada por ele durante sete ou oito dias, sendo que naquela data foi abordado por policiais, permitindo o ingresso em sua residência, onde encontraram o entorpecente em questão. Ademais, havia saído há poucos dias da prisão, trabalhava como servente de pedreiro e o dinheiro apreendido era de sua esposa e visava pagar uma parcela do financiamento de uma motocicleta.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça

Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Sua versão não se sustenta.

O policial militar Bruno declarou em Juízo que tinham informações de que o Réu estava traficando em sua residência e na data dos fatos passavam pelo local quando o avistaram do lado de fora, ele aparentou nervosismo e foi abordado, sendo que em busca encontraram a porção de crack, uma lâmina de barbear e dinheiro em notas diversas. Com autorização do Réu entraram em sua casa, encontraram sua companheira e ali, em revista, localizaram na cozinha um pote de sorvete que continha as porções de cocaína, outra lâmina de barbear, sacos de sacolé e uma balança digital, tendo o Réu assumido a droga, sem falar a destinação. Ademais, ele é conhecido pelo tráfico, não aparentava estar sob efeito de droga e a pedra de crack poderia ser fracionada. Em linhas gerais, este foi o teor do depoimento do policial militar Tarcísio.

A conduta do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, tanto trazia consigo, quanto tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a considerável quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, convido asseverar, também, que ele é conhecido dos meios policiais pela prática deste crime, sendo, ademais, que não exerce ocupação lícita comprovada, em especial, não podendo se ignorar, que ele era recém-egresso do sistema penitenciário. Não se deve ignorar, ainda, que ele possui duas condenações criminais por tráfico de drogas (cf. fls. 35/36 e 36). Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas – sequer comprovado - não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas, o que impede a desclassificação pretendida e, conseqüentemente, a análise da insignificância dessa conduta.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, não podendo ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência ao depoimento deles. Cabe salientar que a versão apresentada pelos policiais merece total credibilidade, já que fornecida com clareza, coerência, riqueza de detalhes e corroborada pelo auto de exibição e apreensão e laudo pericial.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª

C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Assim, tem-se o depoimento do Réu que, por motivos óbvios, possui intenção de se isentar das penas da narcotraficância e, de outro lado, o depoimento uníssono dos policiais militares, agentes públicos que contaram com detalhes a prisão do Réu, nada sendo levantado e muito menos comprovado contra eles, de forma que viesse a colocar em xeque seus depoimentos.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória, sendo que prova da mercantilização não é necessária para a prática do crime, quando presentes os requisitos comprobatórios do tráfico, como na hipótese em julgamento. Oportuno salientar, neste panorama, que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado ostenta maus antecedentes, consistente em condenações criminais sem efeitos para reincidência, incluindo por tráfico de drogas (fls. 33, autos nº 0002036-43.2013.8.26.0201; fls. 33/34, processo nº 0001348-25.2011.8.26.0210; fls. 34/35, autos nº 0003582-24.2004.8.26.0210; fls. 35, autos nº 0003587-46.2004.8.26.0210; fls. 35, autos nº 0003644-20.2011.8.26.0210; fls. 35/36, processo nº 0004431-59.2005.8.26.0210 e fls. 36, processo nº 0005150-31.2011.8.26.0210) e que podem ser utilizadas sem risco de incorrer em bis in idem com a reincidência porque são processos diversos dos que serão abaixo mencionados, mas que demonstram personalidade voltada para a prática das mais diversas condutas antissociais e exige resposta estatal mais vigorosa. Não bastasse, também é o caso de majorar sua pena-base, considerando a considerável quantidade de entorpecente apreendida para os padrões desta cidade, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em 1/5 (um quinto) e a fixo inicialmente em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em 1/4 (um quarto) em razão da dupla reincidência (cf. fls. 33, processo nº 0000130-25.2012.8.26.0210 c.c. fls. 53 e fls. 34, processo nº 0003568-93.2011.8.26.0210 c.c. fls. 53), atingindo o patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Sendo reincidente e pela maior perniciosidade do crime, pelos motivos expostos linhas acima, o Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que não há prova de ocupação lícita, demonstrando que se dedica, exclusivamente, à atividade criminosa do comércio de drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Importante consignar que caberia à Defesa a prova de que o Acusado faria jus à causa de diminuição mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, ou seja, “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Desta forma, o Réu deveria indicar, através de provas robustas que trabalhava e não se dedicava a atividades criminosas, afastando o quanto foi comprovado pela Acusação, isto é, que estava em ato de traficância.

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e

circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: “Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos

motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita” (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizada quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu (fls. 09), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu WILLIAM MELQUIDES DE CARVALHO, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em seu piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com ele, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário apreendido, em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, reincidente, descontente com a decisão deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo porque mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que, preso em flagrante, fosse posto em liberdade depois de condenado por crime equiparado ao hediondo, ficando indeferido o pedido da douta Defesa.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA